

1500950-42.2021.8.26.0666

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente e estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade e permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão "reiteradamente ou não", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500950-42.2021.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500950-42.2021.8.26.0666

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267359/2021 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 20576204 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2176/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2267359 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS DONISETTE DE SOUZA FERNANDES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de MARCOS DONISETTE DE SOUZA FERNANDES e ANTONIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES, já qualificados nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, Lei de Drogas, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, afirmando que, ao menos até o dia 30 de setembro de 2021, por volta das 6 horas30min, na Rua Guilherme Luck, nº 326, Jardim Planalto, na cidade e comarca de Artur Nogueira, para a prática reiterada ou não do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 6horas30min, na Rua Guilherme Luck, nº 326, Jardim Planalto, na cidade e comarca de Artur Nogueira, os réus já devidamente qualificados nos autos, agindo em conjunto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam

consigo, para fins de tráfico, um total de 50,1g (cinquenta gramas e dez centigramas) de maconha em invólucros plásticos, bem como 3 (três) balanças de precisão e materiais plásticos, sendo tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, os réus associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas, guardando entorpecente na casa em que moravam e ali, usando balança de precisão, pequenos sacos plásticos e outros utensílios, fracionando drogas para confecção de porções menores a serem depois vendidas por eles para terceiros. Nas circunstâncias acima delimitadas, no bojo da referida empreitada criminosa conjunta, guardavam em sua residência a referida quantidade de droga, bem como objetos destinados ao seu fracionamento e acondicionamento em porções individuais para venda a terceiros. Ocorre que a Polícia Civil obteve informações a respeito da empreitada criminosa dos irmãos e empreenderam diligências preliminares, logrando angariar elementos que subsidiaram a expedição de mandado de busca domiciliar para apuração dos crimes em foco. Com efeito, quando investigadores de polícia juntamente com guardas municipais, chegaram na casa dos denunciados em cumprimento à mandado de Busca e Apreensão referente ao processo de nº 1500947-87.2021.8.26.0666, ao ser questionado sobre o paradeiro de seu irmão, MARCOS afirmou que ANTONIO já havia saído para recolher reciclagens na rua. Ato seguinte, ao realizarem buscas pelo local, os Guardas encontraram balanças de precisão, bem como objetos com odores e resquícios de drogas, além de 50,1g (cinquenta gramas e dez centigramas) de maconha em invólucros plásticos, droga que estava no quarto de ANTÔNIO MARCOS. Apurou-se também, que diversas denúncias foram recebidas em solo policial, em que alegavam o envolvimento de MARCOS DONISETTE DE SOUZA FERNANDES, vulgo "Soro", à prática de tráfico de drogas na cidade de Artur Nogueira, bem como seu irmão ANTONIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES, vulgo "Nezão" que o ajudava na redistribuição dos entorpecentes. Após as buscas na residência dos denunciados, os policiais encontraram ANTONIO MARCOS na rua, e ao ser abordado, foram encontrados R\$55,00 (cinquenta e cinco reais) em notas diversas e um cigarro de maconha.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

O artigo 35 da Lei 11.343/06 assim descreve o delito de associação para o tráfico: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa

Já o tipo objetivo do topo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente e estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade e permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão "reiteradamente ou não", as decisões dos tribunais tem se consolidado neste sentido. O objeto material e jurídico é a paz pública.

Trata-se de crime doloso, com especial fim de agir, qual seja, o de traficar drogas ou maquinários. Requer o agrupamento de pelo menos duas pessoas, com ajuste prévio e certa estabilidade de propósito. É um crime autônomo, pois para que esteja caracterizada a associação para o tráfico é dispensável o êxito nas práticas dos crimes dos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas.

No caso em exame, há prova da existência dos crimes de tráfico e de sua autoria. A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/28), pelos laudos periciais (fls. 29/30 e fls. 207/209) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o Investigador de Polícia, Gabriel de Queiroz, na fase policial, disse que que é Investigador de Polícia desta Delegacia de Artur Nogueira, e nesta data, na companhia do também Investigador de Polícia Leonardo Pousada do Amaral e com o apoio dos Guardas Municipais GCM Liberato, GCM Menezes, GCM Santos, GCM Heder, os quais, deram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, referente ao processo nº 1500947-87.2021.8.26.0666, expedido pela Vara Única do Foro de Artur Nogueira. Que referido mandado foi fruto de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas, e durante os trabalhos de campo, foram reunidas diversas informações e denúncias de entorpecentes no endereço dos fatos, ofertado pelo Setor de Investigações. Acrescentou que obtiveram informações e denúncias de tráfico de drogas envolvendo um indivíduo que trabalharia como eletricitista nesta cidade, de nome MARCOS DONISETE DE SOUZA FERNANDES, vulgo "Soro", foi apontado por entregar drogas ilícitas para a distribuição. Nesse sentido, apuraram que um indivíduo, irmão de "Soro", conhecido na cidade e "catador de reciclagem", estaria agindo na venda de drogas ilícitas, e tal informação foi confirmada por populares, que já de muitos anos conhecem a atividade ilícita do indivíduo. Conforme os trabalhos de campo realizado, foi apurado que o indivíduo atenderia pelo vulgo de "Nezão", sendo identificado como ANTONIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES, e as drogas chegariam em boa quantidade em sua casa, onde ali seria fracionada, e que seu irmão, MARCOS DONISETE DE SOUZA FERNANDES, participava e também o auxiliava, na empreitada criminosa. Assim foi representado pela ordem de busca e apreensão domiciliar, a ser cumprida na Rua Guilherme Luck, 326- Jd. Planalto, nesta cidade, e de posse da medida autorizadora, nesta data, diligenciaram ao local, com o apoio dos Guardas Municipais. Estando naquele local, foi identificado em um cômodo nos fundos do imóvel, a pessoa de MARCOS DONISETE DE SOUZA FERNANDES, e cientificado do teor das diligências, foi indagado se havia algo de ilícito e relacionado com a prática do tráfico de drogas naquele local, sendo negado por ele, e perguntado de seu irmão "Nezão", disse que ele já tinha saído para a rua logo de manhã, para recolher reciclagens. Foi realizada buscas no imóvel de MARCOS, sendo localizado ali, um aparelho celular, 03 balanças de precisão, um rolo de plástico filme, dois frascos/recipientes de cor preta, com forte odor e resquícios de maconha, bem como uma bolsa de notebook, com forte odor e resquícios de maconha, e um selo com a imagem colorida de um leão com óculos em um pedaço de fita adesiva, usado comumente nas embalagens de drogas para identificá-la. Ao ser indagado sobre tais objetos, MARCOS disse que é apenas usuário de maconha e que as compra para o seu consumo. Nas diligências nos demais cômodos daquele imóvel, mais precisamente no quarto de ANTONIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES, vulgo de "Nezão", o qual não estava presente, apenas sua genitora, foi localizado, dois rolos pequenos de plásticos filme, uma embalagem contendo saquinhos plásticos do tipo "bidu", comumente usado para acondicionar drogas, e dois pedaços de maconha, já embalados com plástico filme, que depois pesada em balança não oficial nesta Delegacia, pesou aproximadamente 50 (cinquenta) gramas. Os policiais juntamente com uma equipe da Guarda Municipal, diligenciaram no bairro próximo aquele imóvel e logo encontraram a pessoa de ANTONIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES, vulgo de "Nezão", o qual foi abordado e revistado e com ele foi encontrado o valor de R\$ 55,00 em dinheiro e um cigarro de maconha. e também foi cientificado do teor das diligências em sua casa. Diante dos indícios apresentados, os Policiais conduziram os investigados juntamente com as drogas, dinheiro e objetos até esta Delegacia para as providências de Polícia Judiciária cabíveis ao evento. Em juízo, disse que começou uma investigação realizada pelo setor de investigações gerais, a qual obteve informações de um informante de que pessoa de vulgo "Nezão" era catador de lixo e vendia maconha. Segundo populares a venda ocorria há muito tempo. Identificaram como o ora acusado Antonio e começaram a monitora-lo pra saber as atividades que desempenhava e como

vendia os entorpecentes. Paralelamente a esta investigação, obtiveram informações de tráfico no bairro Blumenau, bem como foram informados de que quem vendia a droga era um eletricitista, que tinha um carro da marca Uno. Além disso, uma das investigadas chamava-se Sara. Após, descobriram que Antonio era irmão de Marco que era eletricitista e que tinha um carro Uno. Descobriram que Marco, conhecido com Soro, também estava envolvido no tráfico, transportando entorpecente. Esclareceram que Marco fazia o transporte e a distribuição, fornecendo, inclusive, para o Bairro Blumenau. Contou ainda o investigador que um dia de campana, viram Marco em contato com uma das investigadas de nome Sara. Na busca pela residência encontraram alguns resíduos, bolsa com cheiro forte de maconha, encontraram dois tabletes de maconha, que estavam no quarto do Antonio e um cigarro para uso pessoal. O celular do Marco foi apreendido e quando voltou da perícia, retornou com fotos de tijolos de maconha inclusive pesados com a balança apreendida. Fotos de tijolos dentro de bolsa. Inclusive tinha contato com Jonathan do bairro Blumenau através de ligações. Relatou a existência de uma laudo mostrando muitas fotos do celular do Marco com fotos de tijolos de maconha, bem como depósitos enviados a uma mulher de Mogi, cujo marido foi preso com drogas. Disse que Marco realizava o transporte e distribuía os entorpecentes e Antonio fazia uma venda mais caseira. O relatório informado ainda não foi feito. No cômodo do Marcos, que era aos fundos, foi localizada uma bolsa com odor de maconha, uma balança maior e forte cheiro de maconha. As embalagens disse não ter certeza onde foram encontradas, mas acredita que tenha sido no quarto do Marcos. Acerca das denúncias anônimas, disse que além delas foi realizadas diligências de campana e observação. Foi assim que descobriram que o Marco estava residindo na mesma casa do Antonio. Disse que o mandado de busca foi em três endereços, o da ex-esposa de Marcos e de um irmão dos dois acusados.

A testemunha de acusação, Leonardo Pousada do Amaral, em fase policial, prestou suas declarações no mesmo sentido do seu colega.

A testemunha de acusação, Raphael dos Santos, disse em fase inquisitorial que é Guarda Municipal e foi solicitado a dar apoio aos policiais Civis desta Delegacia para cumprir mandado de buscas, sendo certo que duas viaturas da Romu foram destacadas para acompanhar os policiais, na VTR 01 estava o depoente, juntamente como os GCMS Liberato e Renzo, e a VTR 02, com os integrantes Menezes, Pascoal e Gonçalves. Durante a diligência pela Rua Guilherme Luck, 326, Nosso Lar, local esta residência de Antonio Marcos Souza Fernandes. Com a chegada das viaturas, foram informados pela genitora de Antonio que este não se encontrava, porém estava pelo bairro, então passaram a fazer patrulhamento pelo referido bairro, quando em determinado momento pela rua Angelo Tebaldi, a equipe do depoente logrou êxito em localizar a pessoa de Antonio, sendo que em busca pessoal foi localizado a quantia de R\$ 55,00 em moeda corrente, e depois foi encontrado no carrinho em que ele empurrava um cigarro de maconha, e após ser revistado, Antonio foi devidamente conduzido a esta delegacia. Além disso, tomou conhecimento que na residência de Antonio foi localizado dois pedaços de maconha e além de balanças de precisão. Em juízo, disse que a equipe foi designada para dar apoio a polícia civil e, chegando na casa do Antonio, foram informados pela genitora que ele não estava no local, então juntamente com a equipe fez patrulhamento na região e localizaram o acusado. Ao abordarem, foi localizado cinquenta e cinco reais. Não adentrou na casa. Depois que localizaram Antonio, levaram até a residência.

A testemunha de defesa, Jaqueline Aparecida Fernandes, disse que Marcos Donisete é seu pai e que este não tem envolvimento com tráfico de drogas, que é apenas usuário. Disse que o pai é eletricitista, faz instalação elétrica, bicos e que sempre atuou como eletricitista.

A testemunha de defesa, Beatriz Eloisa Fernandes, disse que é filha de Marcos Donisete, que a atividade profissional do pai é eletricitista, que o pai morava sozinho, mas visitava a mãe todos os dias.

ANTONIO MARCOS DE SOUSA FERNANDES, em seu interrogatório na fase de polícia, disse que apenas é usuário de maconha e ingere cerveja. Informou que recolhe reciclagem, e já ficou preso três vezes por tráfico de drogas. Sobre os fatos imputados, negou estar envolvido com a prática do tráfico de drogas na cidade de Artur Nogueira. Sobre as duas porções de drogas localizadas em seu quarto, bem como dois rolos

pequenos de plásticos filme e uma embalagem contendo saquinhos plásticos do tipo "bidu", disse as drogas são para seu consumo e que compra os objetos para embalar a maconha que adquire. Por fim, negou qualquer envolvimento com a venda de drogas. Em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário e que as drogas encontradas em seu quarto são para exclusivo uso. Não sabia que as balanças de precisão estavam em sua residência. Afirmou que não tem muito contato com seu irmão, o corréu Marcos, e que adquirem os entorpecentes de vendedores diversos. Disse que não conhece Samantha e Diego.

MARCOS DONISETTE SOUZA FERNANDES, em seu interrogatório, na fase policial, disse que reside na Rua Guilherme Luck, n. 326- Jardim Planalto, na cidade de Artur Nogueira, no mesmo imóvel em que seu irmão Antônio Marcos de Souza Fernandes, vulgo "Nezão", nos fundos. Afirmou ser usuário de maconha há seis anos. Informou trabalhar como eletricitista há 20 anos aproximadamente, com renda mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre os fatos imputados de que estaria envolvido com a prática do tráfico de drogas na cidade de Artur Nogueira, mencionou ser apenas usuário de droga, negando qualquer envolvimento com a venda de drogas na cidade. Ao ser indagado sobre seu irmão também estar envolvido com tráfico de drogas, disse que o irmão recolhe reciclagens e já ficou preso em outras ocasiões. Além disso disse saber que o irmão também é usuário de drogas, mas não pode afirmar se ele está vendendo ou participando na prática do tráfico de drogas. Sobre a bolsa, usada para guardar notebook localizada no cômodo de onde reside, com odor forte e resquícios de maconha, disse que referido objeto foi localizado na reciclagem. Sobre as balanças de precisão que foram localizadas na sua residência disse que a balança maior e uma pequena foram encontradas junto com a bolsa de transportar notebook, na reciclagem. Perguntado sobre a terceira balança menor que foi encontrada em sua residência, disse que já possui há algum tempo e que usava para pesar materiais, porcas e arruelas, e para pesar os objetos que presta serviço de eletricitista. Sobre os dois frascos e recipientes pretos com forte odor e resquícios de maconha, disse que eles pertencem e que referidos objetos são usados para guardar as drogas que ele compra para seu uso pessoal. Perguntado sobre um selo com a imagem colorida de um leão com óculos num pedaço de fita adesiva, localizado em sua casa, disse que veio numa porção de maconha que comprou para usar. Perguntado se no seu aparelho celular possui alguma evidência, indício, fotografias ou algo relacionados com drogas, disse que não há nada ligado a drogas, negando veementemente a prática, participação no tráfico de drogas. Esclareceu que na data dos fatos, logo pela manhã, estava em sua residência quando ali chegaram os policiais os quais noticiaram a ele sobre uma ordem de busca e apreensão em sua residência, haja vista ter denúncias do seu envolvimento com tráfico de drogas sendo que acompanhou as buscas em sua residência, onde ali foram localizados os objetos. Negou a traficância. Afirmou que usava a balança de precisão para pesar as drogas que pudessem ser vendidas em quantidade inferior a adquirida. Disse que Samantha era quem fornecia as drogas, por isso tinha seu contato e Diego, seu companheiro, está preso. Fazia os pagamentos mensalmente por meio de depósito em conta corrente da Samantha. Afirmou que comprava de 150g a 180g por mês, mas em um mês chegou a comprar 500g, pagando R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para evitar que tivesse que deslocar muitas vezes para adquirir os entorpecentes.

Embora tenham negado os fatos, a versão dada pelos acusados não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foram incapazes de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da

ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor, tiveram estas plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009.

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013.

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante". TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018.

No mais, pelos objetos encontrados na residência dos acusados, bem como pelas imagens obtidas no celular do acusado, Marcos, percebe-se o envolvimento de ambos no tráfico de drogas e não somente a aquisição para consumo próprio.

Além disso, não é crível que um usuário, com a função de eletricitista, consiga despendar em um mês de R\$3.000,00 para compra de maconha para uso próprio. Do mesmo modo, não é factível que o traficante tenha permitido o pagamento a prazo de tal quantidade de entorpecentes.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No é o caso dos autos.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Quanto ao delito de associação, entendo que não restou devidamente comprovada a associação para o tráfico ilícito de entorpecente, ou seja, a reunião estável e permanente de duas pessoas para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, os delitos previstos nos artigos 33, "caput", e parágrafo 1º, e 34, ambos da Lei n. 11.343/06. Isso porque, as provas dos autos não indicam a função de cada um na sociedade e nem mesmo a ligação entre eles durante a atividade criminosa.

Passo a dosar a pena.

a) ANTONIO MARCOS DE SOUSA FERNANDES

Primeira Etapa. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo as reprimendas nos patamares mínimos, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Etapa. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. A confissão relativa ao uso da droga não enseja a incidência da atenuante quando da condenação por tráfico:

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, observa-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, e não merece reparo. O benefício foi negado ao paciente por ter ele assumido, tão somente, a posse da droga para consumo próprio, e não propriamente o tráfico de entorpecente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a confissão espontânea do agente, sentenciado por tráfico de entorpecentes, de ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. A propósito: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

PACIENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO, ALEGANDO SER MERO USUÁRIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu admita a prática do crime que lhe é imputado, contribuindo, assim, com o deslinde da persecução criminal. Na espécie, o Tribunal de origem destacou que o paciente negou a prática delitiva em juízo, alegando que teria comprado o entorpecente apenas para consumo e não para a mercancia, razão pela qual não deve incidir, na espécie, a referida atenuante. 2. Ante o não acolhimento do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resta prejudicado o pleito de compensação da agravante da reincidência com a referida atenuante. 3. Habeas corpus não conhecido." HC 373.054/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 4/5/2017.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. TRANSPORTADOR DE DROGAS. MULA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 65, III, 'D', DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE QUE NÃO SE APLICA PARA CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS QUE RECONHECE APENAS O USO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de prova, que a ré, presa enquanto praticava o transporte internacional de drogas, integrava organização criminosa, sendo inviável afastar tal constatação, em razão do vedado revolvimento fático-probatório, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A confissão espontânea pela prática de uso de drogas não enseja a aplicação da referida atenuante se o réu foi condenado por tráfico de drogas, conforme jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido." AgRg no AgRg no AREsp 1.053.604/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017. STJ, HC 431541/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Mantenho a pena-base fixada.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento.

Cabível o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que a pena poderá (e não deverá) ser reduzida. Ora, a aplicação dessa diminuição e a sua quantidade não ficam ao arbítrio puro do julgador; a própria lei especial, seu art. 42, informa quais os critérios devem nortear a fixação da pena: a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, além de primário, não há nos autos notícias que o réu se dedique a

atividades ilícitas ou faça parte de alguma organização criminosa. Dessa forma, reduzo a pena em 2/3 para fixá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa. Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu primário, em respeito ao §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o aberto.

Em vista da pena aplicada e do crime cometido sem grave ameaça ou violência, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo à entidade(s) definidas pelo Juízo da Execução

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

b) MARCOS DONISETE DE SOUZA FERNANDES

Primeira Etapa. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo as reprimendas nos patamares mínimos, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Etapa. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento.

Cabível o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que a pena poderá (e não deverá) ser reduzida. Ora, a aplicação dessa diminuição e a sua quantidade não ficam ao arbítrio puro do julgador; a própria lei especial, seu art. 42, informa quais os critérios devem nortear a fixação da pena: a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, além de primário, não há nos autos notícias que o réu se dedique a atividades ilícitas ou faça parte de alguma organização criminosa. Dessa forma, reduzo a pena em 2/3 para fixá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu primário, em respeito ao §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o aberto.

Em vista da pena aplicada e do crime cometido sem grave ameaça ou violência, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo à entidade(s) definidas pelo Juízo da Execução

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar ANTONIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES e MARCOS DONISETE DE SOUZA FERNANDES pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem, as penas privativas de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, fixadas no valor unitário mínimo, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Em vista da primariedade e do regime inicial fixado, concedo aos acusados o direito de apelar em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF.

P.R.I

Artur Nogueira, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA